

1500805-24.2021.8.26.0621

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo César Ribeiro Meireles

Comarca: Guaratinguetá

Foro: Foro de Guaratinguetá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 09/03/2022

... por porte de arma de fogo. Afirmou que o tráfico se dava a cerca de 30 (trinta) metros de uma escola e cerca de 20 (vinte) metros de uma igreja.

O réu Emerson, em seu interrogatório, negou a prática do crime de tráfico, alegando não conhecer o menor em questão. Alegou que foi abordado aleatoriamente e que, logo após esse fato, os policiais trouxeram o menor, afirmando que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guaratinguetá 1ª Vara

Av. Dr. Ariberto Pereira da Cunha, 280, Portal das Colinas - CEP 12516-410, Fone: (12) 3125-4133, Guaratinguetá-SP - E-mail: guarat1@tjsp.jus.br

CONCLUSÃO

Em 08 de março de 2022 faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito, Dr. Paulo César Ribeiro Meireles. Eu, _____, Escr., lavrei este termo.

SENTENÇA

Processo nº:

1500805-24.2021.8.26.0621 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EMERSON CARLOS PAIVA DE ARAUJO

Juiz de Direito Dr.: Paulo César Ribeiro Meireles

VISTOS OS AUTOS.

EMERSON CARLOS PAIVA DE ARAUJO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Presentante do Ministério Público, como incurso nas penas do artigo 33, "caput" e artigo 40, inciso III, da Lei n 11.343/06 e artigo 244-B, caput, da Lei n. 8.069/90, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, porque, no dia 08 de Setembro de 2021, por volta de 16 horas e 45 minutos, na Rua Tamandaré, n. 859, bairro Jardim Tamandaré, nesta cidade e Comarca, mantinha em sua posse e em depósito, para fins de consumo de terceiros, drogas consistentes em m 186 g (cento

e oitenta e seis gramas) de Cocaína e 66 g (sessenta e seis gramas) de "crack", sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo a denúncia, o Réu agiu em concurso de agentes com o adolescente WILSON JOSÉ DA SILVA JÚNIOR.

Logrou-se apurar que o Réu corrompeu o menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal.

Nas circunstâncias de tempo supra, avisados das atividades criminosas dos agentes, policiais militares flagraram os agentes comercializando entorpecentes e, devido a este fato, submeteram-nos à busca pessoal. Foram encontrados em poder do Réu 60 (sessenta) pedras de Cocaína, 15 (quinze) microtubos de eppendorf, contendo "crack", R\$ 237,00 (duzentos e trinta e sete reais) em dinheiro e um aparelho celular para contatar usuários e fornecedores.

Ademais, foram encontrados em poder do menor 62 (sessenta e duas) cápsulas eppendorf, contendo Cocaína, 25 (vinte e cinco) pedras da mesma droga e R\$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais).

Em seguida, os policiais rumaram para um terreno baldio no qual, segundo denúncias, o Réu guardava e comercializava os entorpecentes. No local, foram apreendidos mais de 104 (cento e quatro) pedras de Cocaína e 148 (cento e quarenta e oito) microtubos eppendorf de "crack".

Vale destacar que o Réu praticou o comércio de entorpecentes nas proximidades da instituição de ensino Zezé Figueiredo e de uma igreja, sem qualquer pudor em disseminar o uso de drogas.

Frente a tais evidências, o Réu foi preso em flagrante delito, como garantia da ordem pública.

Vieram aos autos, Auto de Prisão em Flagrante (págs. 01/03); Boletim de Ocorrência (págs. 11/14); Laudo de Exibição e Apreensão (págs. 15/16); Imagens dos itens apreendidos (págs. 17/23); Laudo Pericial Definitivo (págs. 26/29); Laudo de exame químico-toxicológico (págs. 116/119); Folha de antecedentes (págs. 61/65, 151/157). A denúncia foi recebida às páginas 128 a 131.

Manifestação do Ministério Público (pág. 72), requerendo convertida a prisão em flagrante do Réu em prisão preventiva.

O Réu apresentou manifestação às páginas 73/76, 78/88. Requereu a concessão de liberdade provisória sem fiança ou relaxamento da prisão. Alegou que houve flagrante forjado. O acusado negou a prática do crime em tela.

Convertida prisão em flagrante em prisão preventiva (págs. 89/92, 96/97, 111/112). Citado o Réu (págs. 133/135, 159), este apresentou defesa preliminar às páginas 140 a 148. Negou haver corrompido o menor citado. Requereu absolvição primária do Réu pelo crime de tráfico de drogas. Requereu a revogação da prisão preventiva do Réu. Requereu a expedição do alvará de soltura do Réu.

Manifestação do Ministério Público pela manutenção da prisão preventiva do Réu (págs. 161/164).

Indeferido pedido de revogação da prisão preventiva.

Designada audiência de instrução e julgamento e intimados a testemunha e o Réu (págs. 165/16, 170/173, 177/178, 182/183).

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas 2 (duas) testemunhas, arroladas pelo Ministério Público e pela Defesa, sendo, ao final, o Réu interrogado, conforme páginas 186 a 190.

Em alegações finais (págs. 193/197), o Doutor Promotor requereu a procedência da Ação, alegando que a existência do crime de tráfico de drogas restou devidamente comprovada, bem como a sua autoria resultou indiscutível. Quanto à dosimetria da pena, considerando os maus antecedentes e a reincidência do acusado (págs. 61/65, 151/157), pois possui condenações transitadas em julgado, é vedada a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei n 11.323/06. Afirmou que há causas de aumento de pena do art. 40, incisos. III e VI, da Lei de Drogas. Requereu que o regime inicial seja fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP. Requereu que seja majorada a pena em razão da diversidade de espécies de entorpecentes.

A Defesa do Réu, por sua vez (págs. 199/205), postulou pela improcedência da ação penal, alegando que houve flagrante forjado. Alegou que o Réu não conhecia o menor

em questão e, portanto, não agiu em concurso de pessoas, ou mesmo corrompeu o menor. Alegou que o infante possui passagens pelo delito de tráfico. Alegou que o Réu possui salário lícito, não se valendo do dinheiro de meios ilegais. Pugnou pela absolvição do Réu e, caso não seja esse o entendimento, pelo estabelecimento da pena no mínimo legal, fixando o regime semi-aberto para início do cumprimento da pena. Requereu a concessão do direito ao Réu de recorrer em liberdade.

Vieram-me conclusos os autos.

Este, em síntese, é o relatório.

FUNDAMENTO.

Cuida a espécie presente de denúncia oferecida em razão de crime de tráfico de entorpecentes dito praticado pelo Réu, que mantinha em sua posse e em depósito, droga para fins de consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ademais, o Réu teria corrompido menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal, com o qual foram encontrados drogas, dinheiro e um celular, mais a associação para o tráfico.

Ausentes preliminares, quanto ao mérito, no que diz respeito à materialidade do delito, observamos que as substâncias entorpecentes foram constatadas como sendo realmente as drogas em questão, Cocaína e "crack", prévia e definitivamente, de acordo com o Laudo de exame químico-toxicológico páginas. 116 a 119 e Laudo Pericial Definitivo às páginas 26 a 29.

A autoria, por sua vez, é igualmente certa e indubitosa a partir do que nos autos consta, senão vejamos:

M.C.G.P., policial militar, ouvido em juízo, declarou que, no dia do flagrante, o menor fugiu da equipe de policiais e o Réu foi abordado imediatamente. Ambos foram revistados. Foram encontrados 15 (quinze) microtubos de eppendorf de Cocaína, e cerca de sessenta pedras da mesma droga na cueca do Réu, além de certa quantia em dinheiro (disse não lembrar a quantidade exata de drogas encontrada com o menor ou o valor certo encontrado com o Réu). Informou que, posteriormente, foram encontrados mais entorpecentes localizados em um terreno que havia sido indicado pela mesma denúncia que indicou o Réu e o menor como traficantes. Disse que o Réu e o menor foram vistos juntamente em ação.

No mesmo sentido foram as declarações do policial militar P. P. S.S., que também participou da diligência e corroborou a narrativa de seu colega de farda. Relatou que já apreendeu Emerson por porte de arma de fogo. Afirmou que o tráfico se dava a cerca de 30 (trinta) metros de uma escola e cerca de 20 (vinte) metros de uma igreja.

O réu Emerson, em seu interrogatório, negou a prática do crime de tráfico, alegando não conhecer o menor em questão. Alegou que foi abordado aleatoriamente e que, logo após esse fato, os policiais trouxeram o menor, afirmando que os dois estavam atuando em conjunto. Alegou desconhecimento do terreno no qual foram encontradas drogas. Alegou que não portava entorpecentes no momento da abordagem policial.

Vale lembrar que as afirmativas feitas pelos agentes policiais têm a presunção "juris tantum" de serem verdadeiras, posto que estão à serviço do Estado para garantir a segurança do cidadão e manter a ordem pública, cabendo a quem alegar eventual falsidade ou conduta ilícita da parte dele, prová-la ou, ao menos, trazer ao juízo indícios coerentes da dita irregularidade, o que não aconteceu no presente caso.

Neste sentido:

"Quanto ao depoimento de policiais, presume-se que agem eles no cumprimento do dever e nos limites da legalidade, havendo que se repudiar sua palavra somente quando em flagrante dissonância com os demais elementos de convicção trazidos ao processo." (TJSP, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Devienne Ferraz, votação unânime, RT 727/473).

Desta forma, observo que o delito de tráfico está devidamente caracterizado e o Autor corretamente identificado, conforme veremos linhas a seguir.

Os policiais ouvidos em juízo afirmaram que o réu mantinha em sua posse e em depósito, para fins de consumo de terceiros, droga consistente em drogas consistentes m 186 g (cento e oitenta e seis gramas) de Cocaína e 66 g (sessenta e seis gramas) de "crack", sem autorização e em desacordo com determinação legal ou

regulamentar. Além disso, afirmaram que o Réu agiu em concurso de pessoas com um menor.

Ademais, diante da situação de, após a denúncia de tráfico de drogas ser confirmada pela droga encontrada com o Réu e pela quantia de dinheiro que este portava, nada mais justo e até mesmo exigência que os policiais checassem o local no qual foi indicado que o Réu procedia o armazenamento e a venda das drogas, no estrito cumprimento do dever legal, sob pena de até mesmo de suposta prevaricação, no mínimo falta funcional, diante das evidências que no local em questão poderia haver quantidades ainda maiores.

Exatamente como acabou se confirmando com encontro de apreendidos mais de 104 (cento e quatro) pedras de Cocaína e 148 (cento e quarenta e oito) microtubos eppendorf de "crack", sendo a venda de drogas crime permanente, portanto, no terreno ocorria um crime (estava em curso permanentemente), sendo dever da polícia militar a repressão e estancamento de condutas tais.

Diante disso, e não tendo prova ABSOLUTAMENTE isenta em contrário, TENDO sido apreendida drogas e dinheiro para a venda de entorpecentes com Réu, como o comum quando vendem drogas, pois a quantidade encontrada apresentou-se de maneira exorbitante para ser considerada de uso pessoal, não se faz possível acreditar nesta versão apresentada pelo Réu, meramente negativa, conforme já visto supra, tendo em vista que o tipo penal pune aquele que realiza a traficância ou meramente guarda, tem em depósito e porta para fins de tráfico.

Desse modo, o argumento da defesa no sentido de desclassificação do delito não merece prosperar, uma vez que as características da traficância restaram devida e sobejamente comprovadas. Veja-se, a quantidade de drogas encontrados com o Réu impossibilita o pensamento de que as drogas eram para uso próprio, uma vez que era uma quantidade considerada alta, ou seja, impossível pensar que esta droga seria usada pelo próprio acusado em tela. Ademais, devido à ambos os depoimentos das testemunhas relatarem os fatos da mesma maneira, pode-se concluir que o Réu agiu em concurso de pessoas com o menor em questão, havendo praticado, concomitantemente, o crime de corrupção de menor de 18 (dezoito) anos.

Também não prospera a inexistência da corrupção, porque de menor se tratava e se estava, como estava com o Réu praticando delitos, o Estatuto da Criança e do Adolescente é claro para dizer o fato criminoso objetivamente.

Igualmente, o concurso, pelo afirmado pelos policiais, afinal estavam juntos e se apartaram em fuga o menor no momento da chegada.

Neste diapasão, observo que o delito de tráfico, realizado em concurso de agentes e o delito de corrupção de menor estão devidamente comprovados pelo que nos Autos consta.

Também, portanto, o argumento da defesa no sentido de ausência de provas para a condenação do Réu não merece prosperar, pois ficou muito evidente pelas provas produzidas a autoria e culpabilidade do Réu.

Então, quanto à tipicidade tenho que é a exata correlação dos fatos de que se ocupa este processo à norma penal invocada na exordial, pouca coisa resta para dizer, já que o acontecido se ajusta perfeitamente à situação criada em abstrato pelo legislador penal, senão vejamos:

Art. 33, Código Penal – Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Pena – reclusão, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa

Artigo 35, Código Penal – Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de traficar, reiteradamente ou não, quaisquer dos crimes previstos nos arts. 33 caput e § 1º, e 34 desta Lei:

Pena – reclusão, de 03 (três) anos a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Art. 244-B, ECA. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la: Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

Exatamente o que aconteceu no caso, pois nenhuma dúvida há sobre a conduta ilícita do Réu, consoante documentos e testemunhos carreados ao bojo dos autos.

Desse modo, tenho que os delitos se encontram perfeitamente caracterizados e o Autor corretamente identificado.

Logo, a condenação se impõe e a pena a ser aplicada deve ser a prevista para o crime de tráfico, ou seja, mais precisamente a do artigo 33 "caput" da Lei 11.343/06, além da pena prevista para o crime de corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, especificamente a do artigo 244-B, do ECA e a pena por associação de duas pessoas para o fim de traficar, mais precisamente a do artigo 35 "caput" da Lei 11.343/06.

Posto isso, passo a dosar a pena aplicável à espécie, com base nos artigos 59 e 60 do Código de Penal.

I - PENA-BASE

Considerando e atendendo à culpabilidade, tenho que não se revestem os fatos praticados de reprovabilidade anormal ou exacerbada, tendo o dolo sido regular ao tipo; aos seus antecedentes, observo que o Réu apresenta envolvimentos anteriores (págs. 61/65, 151/1571), sendo um deles com trânsito em julgado, não tendo se passado cinco anos entre tal data e o cometimento do presente, pelo que será usado na fase própria para fins de reincidência; à conduta social, não se tem elementos nos autos, pois diz respeito à forma com que se portava no meio em que vive; à personalidade, igualmente não se dispõe de elementos capazes de traduzir a estrutura psíquica do Réu; aos motivos do crime, não há especificação quanto aos motivos que o levou ao delito, possivelmente o lucro fácil, mas tal motivação não é alheia aos delitos do gênero, razão pela qual deixo de considerar essa circunstância em desfavor do Réu; às circunstâncias do crime, respeitante estas, não há nada que refuja à normalidade desse tipo de delito; às consequências do crime, são de extrema gravidade, contudo, tais consequências são inerentes aos delitos dessa natureza; e, finalmente, quanto ao comportamento da vítima, saliente-se que ela em nada contribuiu para esse tipo de conduta delituosa, aliás a coletividade é que é a titular do bem jurídico protegido (saúde pública). Deixo, portanto, de considerar esta circunstância.

Assim, ante a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mau-antecedentes do Réu, fixo sua pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos e a multa pecuniária de 500 (quinhentos) dias-multa, para o delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, em 01 (um) ano de reclusão, para o delito previsto no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90 - ECA e em 3 (três) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, referente ao definido no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, sendo cada dia-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do maior salário-mínimo (art. 43 da Lei n. 11.343/06).

II - PENA PROVISÓRIA

Passo à análise das agravantes e das atenuantes e fixação da pena provisória e, neste sentido, observo que o Réu possui reincidência, conforme sustentado acima, específica, não havendo, atenuantes, portanto, vai a pena aumentada de 1/6, o que resulta em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e a multa pecuniária em 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, para o delito previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/06, em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão para a infração ao artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90 - ECA e em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, por infração ao artigo 35 da Lei n. 11.343/06, sendo cada dia-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do maior salário-mínimo (art. 43 da Lei n. 11.343/06).

III- PENA DEFINITIVA

Na fase, saliento que o Réu não faz jus a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei n. 11.343/06, levando em conta que necessários requisitos cumulativos para a concessão da diminuição, que o agente seja primário,

de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa. Ele tem a reincidência, como vimos, inclusive específica. Veja-se, aliás, que se deve levar em conta a forma de acondicionamento de droga apreendida e a variedade desta, característico do tráfico contumaz, lembrando que este é atividade complexa, estratificada e organizada, desde o plantio, refino e chegada aos pontos de tráfico, como no caso, ainda o delito da associação com menor.

Ademais, considerando presença do artigo 40, inciso III do Código Penal, por haver efetivado o crime de tráfico de drogas nas proximidades de instituição de ensino e estabelecimento religioso, vai a pena majorada de 1/6, resultando em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa (seiscentos e oitenta) dias-multa de prestação pecuniária, sendo cada dia-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do maior salário-mínimo (art. 43 da Lei n. 11.343/06), para o delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

As demais penas permanecem inalteradas e vão definitivas.

DECIDO.

Posto isso, e considerando tudo o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE os pedidos deduzidos na denúncia de páginas 128 a 131, para o fim de CONDENAR EMERSON CARLOS PAIVA DE ARAUJO, já qualificado, como incurso no artigo 33 da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa (seiscentos e oitenta) dias-multa de prestação pecuniária, no art. 35 da Lei. 11.343/06 em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, sendo cada dia-multa, para ambos, no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do maior salário-mínimo (art. 43 da Lei n. 11.343/06), e no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90 - ECA em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

REGIME CARCERÁRIO:

Considerando as circunstâncias judiciais do art. 59, conforme antes examinado, do Código Penal, § 3º, do artigo 33, do mesmo Diploma Penal, à luz do artigo 110, da Lei 7.210/84, ante a nova redação do §1º, do inc. II, do art. 2º, da Lei 8.072/90, que apesar do art. 1º, inc. I, segunda parte, do mesmo Dispositivo, considerar crime comparado a hediondo o tráfico de entorpecentes, estabelece que a pena deve ser cumprida em regime INICIALMENTE FECHADO, então, em relação ao delito do artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06 se dará dessa forma, obviamente ressalvada a competência do Juízo da Execução, na forma do art. 66 da Lei de Execuções Penais Quanto ao que preceitua o art. 387, §2º do CPP, deixo de aplicar neste momento. Isso porque, considerando, o teor do art. 2º, da Lei dos Crimes Hediondos¹, que diz no § 1º que a pena será cumprida inicialmente no regime fechado, independe do quantum fixado (diferente dos crimes comuns), nada há o que se falar em, dado esse tempo da cautelar, de modificação do regime.

A doutrina de G. de Souza Nucci diz que não se trata de um juízo de execução, o qual haverá de ser feito pelo juiz competente no PEC extraído e encaminhado à VEC ao lá ter.

Vale dizer, conforme tal doutrina, a autorização legislativa é para um exame, quero crer, similar ao de detração, MAS APENAS para verificar o quantum de pena que resta do montante fixado em condenação e assim para observar, se nos termos do art. 33 do Código Penal, o resultante fica inferior a um determinado tempo (número de anos), quando não sendo o condenado reincidente e reunidas condições judiciais favoráveis como diz o Código (arts. 59 e 60), pode receber regime mais brando do que indicaria o total inicial absoluto fixado, ou seja, seria, por exemplo, passível um condenado a pena inferior a 8 anos (nesse caso mesmo que superior, descontado o tempo da cautelar, se assim resultasse inferior a 8 anos, aliás, como foi o exemplo doutrinário, se caberia, a critério do magistrado, o regime mais brando, mas não neste que é regime inicial fechado independente da pena, como visto).

Já detração propriamente e progressão, só pode ocorrer na VEC pelo juiz competente que a tudo observará (méritos do condenado, contraditório etc.).

Assim, reservo, conforme a Lei, o exame imediato quanto a isso àquele Juízo, sendo que já será pelo cumprimento dos, em tese, 2/5 ou 3/5 da pena - hediondo - (examinando sobre o comportamento carcerário do condenado e o juízo de

progressão/merecimento), pois seria temerário conceder neste momento, em crime que exija o regime mais gravoso, a quem não o mereça pelo eventual mau comportamento, aliás, e se fosse nessa extensão, os poderes do juiz do conhecimento deveriam ser realmente dilargados para a detração e progressão mesmo e ele careceria, ainda, de elementos pelo Estado para a plena aplicabilidade na prática dessa possibilidade, ou seja, a criação de um sistema de consultas on-line para no momento da sentença observar-se eventual falta grave da Ré preso provisório durante a cautela (modo contrário, correria o magistrado risco de, repiso, conceder algo que redunde na soltura imediata do condenado que, por exemplo, tenha liderado rebelião ou mesmo atacado colegas de cela em clara demonstração de abominável comportamento carcerário).

Veja-se decisão no TJSP confirmando entendimento, recurso de decisão deste mesmo prolator:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA PODER JUDICIÁRIO São Paulo Apelação n. 0009028-

26.2014.8.26.0220 - Guaratinguetá - VOTO N. 30.286 - RELATOR IVAN SARTORI:

"... Por derradeiro, o pedido de detração, com vistas a regime mais brando, é matéria a ser apreciada pelo Juízo das Execuções Criminais, pese o disposto na Lei 12.736/12, que acresceu o § 2º ao art. 387 do CPP. É que, para progressão de regime, necessário bem avaliar os requisitos pertinentes, sem falar na possibilidade de supressão de um grau de jurisdição, em ofensa a princípio constitucional. Nessa linha, julgados desta Casa de Justiça: "(...) embora não se desconheça o teor da Lei n. 12.736/2012, que acrescentou o § 2º ao artigo 387, do Código de Processo Penal, estabelecendo que o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade, infere-se inviável, de igual sorte, a alteração do regime prisional, na hipótese, com esteio no lapso que perdurou a prisão cautelar, porque não se tem notícia a respeito da real situação carcerária dos recorrentes, isto é, se não registram outras condenações ou prisões processuais nem quanto aos seus comportamentos e condutas no cárcere, a revelar não existirem elementos seguros para a correta análise, nesta seara e de pronto, quanto a eventual direito à detração penal, emergindo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, à mingua de informações concretas e, sobretudo, em estrita obediência ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição (...)." (Apelação n. 0009573-71.2012.8.26.0348, 5ª Câmara de Direito Criminal, rel. Juvenal Duarte, j. 13.02.2014); "(...) com relação à detração penal, tem-se que o Juízo de origem ainda não conheceu desta questão. Por esta razão, não se pode, nesta Instância Judicial, suprimir-se, de uma só vez, o devido processo legal (cf. artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal), a manifestação do Juiz Natural (cf. artigo 5º, inciso LIII, da CF) e a garantia ao duplo grau de jurisdição (cf. artigo 5º, inciso LV, da CF), sob pena de vilipêndio à Lei Maior do País. Tudo recomenda, decerto, que se aguarde a decisão a ser produzida no Juízo das Execuções até porque continua vigente o artigo 66, inciso III, alínea 'c', da Lei 7.210/1984, a par do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, inserido pela Lei 12.736/2012 quando já presentes informações precisas para o exame com a minúcia necessária da situação prisional do acusado, para que repercuta na fixação do regime carcerário" (Apelação n. 0078884-36.2012.8.26.0224, 7ª Câmara de Direito Criminal, rel. Roberto Solimene, j. 06.02.2014). Em suma: mantém-se o r. édito monocrático, encampada sua motivação (art. 252 RITJ). Ivan Sartori - Desembargador Relator"

SUBSTITUIÇÃO DA PENA:

Originariamente não se apresentava possível à substituição da restrição da liberdade imposta por quaisquer penas restritivas de direito, já que em crimes da espécie a lei especial vedava expressamente, mas foi suspenso pelo Senado esta parte após julgamento de inconstitucionalidade do STF em controle concentrado. Ipsis litteris:

§ 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. (Vide Resolução nº 5, de 2012)

Porém, não se apresenta possível à substituição da restrição da liberdade imposta por quaisquer penas restritivas de direito, devido à quantidade de pena, que se resultou superior a 04 (quatro) anos (art. 44, I do Código Penal), e a reincidência existente, específica.

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA:

O crime pelo qual restou condenado o Réu tem vedação expressa do benefício do sursis, independentemente do quantum da pena imposta, a qual na maioria das vezes também impede a obtenção do benefício (art. 44, da lei 11.343, de 23 de agosto de 2006 e 77, do Código Penal).

DIREITO DE RECURSO EM LIBERDADE:

Considerando que o Réu respondeu a todo o processo preso, assim continuará, com mais razão agora que condenado, já que, inclusive, reincidente específico, assim, conforme é o entendimento correntio da jurisprudência nacional a qual me filio.

Recomende-se, portanto, o condenado na prisão em que se encontra.

Após o trânsito em julgado lance-se o seu nome no Rol dos Culpados (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição da República).

Deixo de condenar o Réu em custas processuais, conforme alínea "a", do parágrafo 9º, do art. 4º, da Lei Estadual n. 11.608, de 29 de dezembro de 2003, porque assistido por advogado nomeado pelo convênio DPE/OAB (pág. 77).

P.R.I.

Guaratinguetá, 08 de março de 2022.